

1500251-46.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... ausência de provas quanto à prática de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requereu para que seja desclassificada a conduta para a prática do art. 28 da lei 11.343/06. Por fim, em caso de condenação no crime de tráfico, pediu para que a pena seja fixada no mínimo legal e que o acusado possa apelar em liberdade (fls. 197/206).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500251-46.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500251-46.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2041611/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 16201891 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI,

517/21/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2041611 - DEL.POL.BIRIGUI, 517/21/309 -

DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK RENAN ROMAN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1500251-46.2021.8.26.0603 (Controle 358/2021)

VISTOS.

PATRICK RENAN ROMAN, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito,

denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Siqueira Campos, nº 1388, Jardim Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e Comarca de Birigui, tinha em depósito 41 (quarenta e um) eppendorfs de cocaína, pesando um total de 36,68 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais de fls. 17 e 73/75.

Apesar de mantido preso na audiência de custódia (fls. 49/51), o acusado foi solto mediante decisão proferida em sede de habeas corpus, autorizando-o a responder ao processo em liberdade (fl. 157), sobrevindo expedição de alvará de soltura.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 97), cuja peça foi juntada às fls. 95/96, sobrevindo o recebimento da denúncia em 16 de maio de 2021 (fls. 127/128).

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas em comum, sobrevindo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 185/186).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 190/195).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu, pela ausência de provas quanto à prática de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requereu para que seja desclassificada a conduta para a prática do art. 28 da lei 11.343/06. Por fim, em caso de condenação no crime de tráfico, pediu para que a pena seja fixada no mínimo legal e que o acusado possa apelar em liberdade (fls. 197/206).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o boletim de ocorrência (fls. 08/10); a nota de culpa (fl. 06); o auto de exibição e apreensão (fl. 11); o relatório final (fls. 76/77); o laudo de constatação prévia (fl. 17); o laudo pericial (fls. 102/104); o depósito judicial (fl. 71); os depoimentos das testemunhas e as indigestas negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Na delegacia, o réu negou a prática criminosa, dizendo que a droga encontrada era para uso próprio (fl. 05).

Em juízo, acrescentou que adquiriu o entorpecente de um desconhecido, na Vila Bandeirante, e que prefere comprar em grande quantidade. O dinheiro apreendido era oriundo do seu trabalho de vendedor de roupas (fls. 185/186).

Contudo, a negativa apresentada pelo acusado está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Com feito, as testemunhas Demerson Luiz Moreno e Marcio Agatielo, policiais civis, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, relataram que, na data dos fatos, dirigiram-se até a residência do acusado, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, por denúncias de prática de tráfico de drogas. Na cômoda do réu, localizaram um pote roxo, com 41 pinos "eppendorf", contendo cocaína, e na gaveta mais R\$ 77,00, em notas diversas. O acusado confirmou que adquiriu os entorpecentes para uso pessoal e que pagou R\$ 10,00 por cada pino (fls. 03, 04 e 185/186).

Os relatos dos policiais evidenciam, portanto, que o réu incidiu na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, já que apontou a apreensão de considerável quantidade de droga, de dinheiro e que houve solicitação de mandado de busca domiciliar em razão de denúncias da prática de tráfico de drogas no local.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ela a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

No que se refere ao entorpecente, a perícia apontou que consiste realmente em "cocaína" (exame químico-toxicológico de fls. 102/104). De outra parte, a quantidade de entorpecente apreendido, ou seja, 36,68 gramas de cocaína, as circunstâncias da abordagem do réu (denúncia de tráfico de drogas na residência); a forma de acondicionamento da droga (embaladas em porções, prontas para o comércio), a apreensão do dinheiro, estão a caracterizar a traficância, tornando-se irrelevante o fato de não ter sido encontrados balanças e outros apetrechos e utensílios utilizados para o tráfico de drogas.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado alega ser proveniente de seu trabalho de vendedor de roupas, porém, não conseguiu comprovar essa versão, arrolando testemunha ou juntado documentos para confirmar a alegação, providência essa que seria de fácil consecução, caso fosse verdadeira a narrativa apresentada em juízo. Ressalto que o simples fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado por "ter em depósito" entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado tinha em depósito 36,68 gramas de cocaína, distribuídas em 41 (quarenta e uma) porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora a defesa tenha alegado que o acusado é usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental. Ademais, o réu, em seu interrogatório, demonstrou-se lúcido.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de

substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser a agente usuário não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem. Descabida, portanto, a pretendida desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei de Drogas.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado ostenta mau antecedente (fls. 207/208 - Processo nº 0002004-80.2017.8.26.0077), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe é desfavorável, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque o réu ostenta mau antecedente, o que afasta a aplicação desse benefício.

Torno definitiva a pena em em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

O acusado foi solto por ordem de habeas corpus e assim deverá continuar a responder ao processo, até o trânsito em julgado da presente.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR PATRICK RENAN ROMAN, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 12/02/2021 até 17/06/2021 (fls. 165/167 - solto por HC), período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restando da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de

drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso. Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do

agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput – e não um crime autônomo –, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que “(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes” (in “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”, 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau” (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

O réu poderá continuar a responder solto a este processo, até o trânsito em julgado, pois assim permaneceu após a concessão da ordem em habeas corpus (fl. 157).

Com fundamento no artigo 58, § 1º, da Lei nº. 11.343/06, e considerando que não houve controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza ou quantidade do entorpecente, ou sobre a regularidade do respectivo laudo, determino a incineração da droga apreendida, expedindo-se o necessário e preservando-se fração para eventual contraprova, se necessário.

Como não restou provada a procedência lícita do dinheiro apreendido à fl. 11 (R\$ 77,00), não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente, razão pela qual, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro depositado à fl. 71.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o “Senad” quanto ao perdimento supradeterminado (dinheiro), instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto ao objeto apreendido (um frasco plástico), apesar de ser instrumento do tráfico de drogas praticado pelo acusado, diante da sua natureza, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro e destruição do objeto apreendido, instruindo-se o ofício com as cópias.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA